

1500353-59.2022.8.26.0530
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa
Comarca: Ribeirão Preto
Foro: Foro de Ribeirão Preto
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/04/2022
... a decisão do E. TJSP:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Recurso da Defesa - Preliminar de ausência de apreensão e perícia do objeto material - Inadmissibilidade - "A materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima - Igualmente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ribeirão Preto
Foro de Ribeirão Preto
3ª Vara Criminal
Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500353-59.2022.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500353-59.2022.8.26.0530
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
HAMILTON DE OLIVEIRA ROMERO e outro

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

VANDER CRISTIANO RIBEIRO e HAMILTON DE OLIVEIRA ROMERO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 21h35min, durante o repouso noturno, agindo em concurso, subtraíram para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, do interior da empresa "Ortopedia Jácomo", localizada na Rua Amadeu Amaral, nº 684, bairro Vila Seixas, nesta cidade e comarca, um notebook da marca Lenovo, modelo Core 5, geração 8, bem apreendido (fls. 23/24) e avaliado (fls. 215) em R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

Na ocasião, já com a intenção de praticarem o crime de furto, Vander e Hamilton passaram trafegar pelas vias desta urbe numa Honda/CG 150 Fan de placa FDY8J31, cor preta, pilotada pelo segundo, até que, ao avistarem a loja de produtos ortopédicos, no endereço já apontado, decidiram agir, aproveitando-se da menor vigilância do período da noite. Assim é que, atuando com perfeita divisão de tarefas e identidade

de propósitos, ambos de forma relevante, enquanto Hamilton permaneceu na motocicleta, garantindo a fuga e a segurança do comparsa, Vander desceu da garupa e, fazendo uso de sua própria força física, danificou a porta frontal de vidro do estabelecimento, lesionando uma das mãos, invadindo o local e se apoderando do computador, retornando para a moto, logo após, em poder de tal bem, ambos consumando o delito patrimonial. Ocorreu que o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) tomou conhecimento da invasão ao local e também das vestimentas dos dois suspeitos – um trajava um colete de mototáxi e o outro vestia uma camiseta marrom e usava capacete –, repassando tais informes para os seus agentes, dois dos quais, em patrulhamento pela Rua João Guião, obtiveram êxito em localizar a dupla trafegando com a Honda/CG 150, conduzida por Hamilton, sendo rapidamente abordados. Em revista, na mochila do garupa Vander, os agentes encontraram o notebook e, ao ser questionado, de maneira informal, este de pronto confessou a subtração do aparelho da loja invadida nas cercanias da Avenida Nove de Julho, empresa para a qual se deslocaram, sendo constatados, então, os danos à porta de acesso à empresa, cuja representante legal compareceu e reconheceu o laptop subtraído. Diante dos fatos, a dupla acabou presa em flagrante e, conduzidos até o distrito para lavratura do respectivo auto, Vander confessou a prática do crime, isentando o comparsa (fls. 08), ao passo que Hamilton negou envolvimento com o delito (fls. 07).

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante dos acusados foi convertida em preventiva (fls. 198/201).

A denúncia foi recebida em 16 de fevereiro de 2022 (fls. 236).

Os réus foram citados (fls. 263/264), apresentando resposta à acusação (fls. 268/269).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento. A prisão preventiva dos acusados foi mantida (fls. 281/282).

Durante a instrução foram ouvidas as declarações da vítima e de uma testemunha comum às partes, bem como os réus foram interrogados (fls. 307).

O Ministério Público, em memoriais de fls. 331/344, requereu a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia, aduzindo que estão provadas a autoria e a materialidade do delito, bem como a causa de aumento de pena do repouso noturno e as qualificadoras do rompimento de obstáculo e comparsaria. Quanto a comparsaria esta se verifica pelas declarações das vítima e imagens das câmeras de segurança constantes do laudo pericial de fls. 310/316. Na dosimetria da pena, pugnou pela fixação da pena-base acima do mínimo legal, pelas circunstâncias do crime e maus antecedentes. Na segunda fase, os réus são reincidentes e na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do repouso noturno, regime fechado, sem possibilidade de concessão de medidas alternativas ao cárcere.

A defesa do corréu Vander, em memoriais de fls. 350/359, requereu o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, pois Vander agiu sozinho, sendo que Hamilton teria parado com a moto a uma distância considerável do local alvo do furto, nada sabendo sobre o ilícito praticado por Vander. Pugnou, ainda, que seja afastada a causa de aumento de pena do repouso noturno, pois não é aplicável nos casos de furto qualificado ou para estabelecimentos comerciais. Na dosimetria da pena, requereu que seja fixada no mínimo legal, seja a atenuante da confissão compensada com a agravante da reincidência, fixação do regime aberto ou semiaberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A defesa do corréu Hamilton, em memoriais de fls. 360/367, pugnou pela absolvição por ausência de provas de sua participação no delito. Este trabalha como mototaxista e estava realizando corrida para Vander. Hamilton não parou a moto na frente da loja, não visualizou a ação de Vander, fato confirmado pelas filmagens constantes do laudo pericial. Alegou ainda ausência da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, assim como as qualificadoras. Em caso de condenação, seja reconhecida participação de menor importância do acusado Hamilton, conforme dispõe o artigo 29, §1º do Código Penal. Na dosimetria, requereu aplicação no mínimo legal e regime aberto, bem como concessão dos benefícios da assistência judiciária.

É o relatório.
Fundamento e decido.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 01/14, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 15/18, pelo Auto de Exibição/Apreensão/Entrega de fls. 23/24, pelo Auto de Avaliação de fls. 215, pelo Laudo Pericial do local dos fatos de fls. 277/280, pelo Laudo Pericial das imagens das Câmeras de Segurança de fls. 308/327, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria do delito é certa e emerge das provas coligidas durante a instrução processual.

A representante da empresa vítima, Viviani Morgana Guirelli Arico, disse que uma pessoa que passava pela rua viu a porta da loja arrombada e entrou em contato. Depois de 20 minutos estava no local. A loja estava revirada, tudo jogado no chão. Viu as imagens das câmeras de segurança, constatando que um deles havia estourado o vidro. Ele entrou e pegou o notebook e uma caixinha que estava na gaveta e saiu correndo. Em contato com a polícia, esta disse que já tinha localizado os autores. Passaram aproximadamente 30 minutos entre chegar no local e a polícia lhe informar sobre a prisão dos réus. Nas imagens dá para ver que um dos furtadores arrombou a porta, entrou correndo, abriu armários e puxou o computador, fez bagunça e saiu correndo. O outro furtador ficou na moto. Pelas imagens, dá para ver a pessoa na moto que ficou do lado de fora. Não se recorda se ele estava de capacete. Parece que a pessoa que lhe avisou sobre o furto chegou a perguntar o que estava acontecendo para o rapaz da moto, mas não sabe o que conversaram.

A testemunha em comum Luiz Otávio Coelho Dias, policial militar, recebeu informação do COPOM sobre um furto na Vila Seixas, em que dois homens em uma moto, um deles de colete de mototáxi, tinham se evadido do local. Em patrulhamento, viram os dois homens com as características informadas. Assim que deram sinais de parada para abordagem, Vender confessou que praticou o furto. Foram ao local e viram a porta de vidro quebrada e fizeram contato com a proprietária, que se apresentou na delegacia. Não se recorda do horário da ocorrência. Os réus foram detidos há uns 5 km do local do furto, na Vila Virgínia, e foram localizados 15 a 20 minutos depois de noticiada a ocorrência. O condutor estava com colete de mototáxi. O notebook estava com Vender em uma mochila, ele era o passageiro da motocicleta e confessou de imediato. Falou que estava com "BO na mochila". Hamilton disse que estava fazendo a corrida para Vender, mas ele parou a moto na porta da loja e viu toda ação de Vender, inclusive o momento em que ele quebrou a porta da loja. Isso foi visto pelas imagens das câmeras cedidas pela vítima. Vender é conhecido por várias ocorrências de furto na região.

O corréu Hamilton, interrogado, disse que tem 49 anos, estudou até a quinta série. Mora atualmente na Rua Amparo, com pessoa debilitada, cuida dessa pessoa. Solteiro. Tem passagens por roubo, furto e homicídio no trânsito, última vez no sistema carcerário em 2014. Estava trabalhando naquele momento e não sabia que o companheiro iria fazer uma loucura dessa. Soube do furto somente quando parou com o passageiro na Vila Virgínia. Não parou em frente a loja, parou a 10 metros da loja, não conseguiu reparar que ele estava furtando. A moto era de um amigo que lhe emprestou para trabalhar. Saiu para trabalhar e encontrou o acusado, que pediu-lhe uma corrida. Parou distante da loja e não viu o que aconteceu; depois foi levá-lo até a Vila Virgínia, onde foi parado pelos policiais. Estava fazendo uma corrida e na volta encontrou Vander na Avenida Mogiana. Não conhecia Vender, embora não fosse pessoa estranha, pois já o tinha visto antes. Ele pediu para leva-lo, primeiro, entre as avenidas Nove de Julho e Independência. Foram embora pois não ele não encontrou a pessoa que estava aguardando na Av. Nove de julho. Ele, então, lhe pediu para leva-lo até a Vila Virgínia, mas pediu para parar antes, em outro local. Quando ele desembarcou na loja, ficou esperando por ele na moto. O que consta no depoimento da delegacia não foi o que relatou. Escutou barulho, mas não deu para perceber o que era. A rua era movimentada e havia pessoa que lhe disse que o corréu entrara na loja. Não entendeu o que a pessoa quis lhe dizer. Ele voltou com algo em

mãos, mas não questionou Vander sobre o que era ou sobre o barulho que ouvira. Estranhou, mas acontece de levar pessoas em locais, ela desce e volta com algo. Trabalha de mototáxi desde 2014, até 22h30. Nunca viu Anderson antes, se o conhecesse não o colocaria sobre sua moto. A rua era movimentada, no centro da cidade, havia pessoa parada em frente de onde ele entrou. Não dava visão para a loja, não viu ele entrando. Ouviu um barulho, mas não conseguiu perceber o que era, estava distraído. Estava de capacete. É comum essas atitudes, inclusive alguns policiais já o alertaram sobre as pessoas que transporta, porém precisa trabalhar. Tem uma pessoa deficiente em casa para cuidar.

O corréu Vander, interrogado, disse que tem 43 anos, estudou até a quinta série, mora na rua Euclides da Cunha 341, casa da tia. Já esteve preso pelo mesmo delito, saiu há três meses. Não conhece Hamilton. Viu ele passando com colete de mototáxi. Pegou mototáxi e foi na avenida Nove de Julho pois tinha pessoa que lhe devia dinheiro na Na Nove de Julho, mas não a encontrou e então pediu para Hamilton levá-lo até a vila Virgínia. Em determinado ponto, viu a loja, pediu para Hamilton parar e entrou na loja. Estourou o vidro com mão, pegou o notebook, assustou-se pois viu uma pessoa com celular na porta da loja e saiu correndo. Sua mão estava sangrando, mas Hamilton não percebeu pois estava escuro, ele também não perguntou nada sobre o notebook. Ao quebrar o vidro, não fez barulho alto. Acredita que ele não escutou devido a movimentação da rua. Sua ação foi de aproximadamente 05 minutos, foi rápida.

Pois bem. Ante as provas constantes dos autos, a condenação dos acusados é medida que se impõe.

O corréu Vander confessou a prática do furto, porém negou a participação de Hamilton. Já o corréu Hamilton negou qualquer envolvimento no crime, alegando que apenas trabalhava como mototaxista e realizava corrida para Vander.

Contudo, vítima e testemunha relataram que, pelas imagens das câmeras de segurança, foi possível constatar a presença dos dois ladrões na cena do crime. Enquanto um deles arrombou a porta vidro da loja, ingressou no estabelecimento e furtou o notebook, o outro permaneceu na motocicleta, assistindo à ação do comparsa, dando-lhe fuga em seguida.

O policial relatou ainda que as informações aportadas via COPOM eram no sentido de que dois homens em uma moto, um deles de colete de mototáxi, realizaram o furto. Em patrulhamento, localizaram os dois homens com as características informadas e, após abordagem, Vander confessou o delito, sendo localizada a res furtiva na mochila que portava nas costas.

Realmente, as imagens do delito (Laudo Pericial de fls. 308/327) não deixam dúvidas quanto a efetiva participação do corréu Hamilton, atuando em comparsaria com o corréu Vander.

As imagens de fls. 310/311 mostram o momento exato em que Vander desembarca da motocicleta em frente à loja para, em seguida, arrombar o vidro e conseguir ingressar no interior. Hamilton, então, estaciona a motocicleta um pouco mais a frente (imagens de fls. 311/314), aguardando Vander sair do estabelecimento para, juntos, fugirem do local (imagens de fls. 315/316).

Não há como acolher a alegação de que Hamilton não teve conhecimento do furto, isso porque do local onde estacionou a motocicleta ele conseguiu assistir a toda ação do comparsa (imagens de fls. 310/316).

Ademais, pelo narrado pela vítima e constatado pelo laudo pericial (fls. 314/315), o delito foi presenciado por uma testemunha, que chegou, inclusive, a conversar com o corréu Hamilton e indaga-lo sobre o que estava ocorrendo na loja.

As próprias declarações de Hamilton em seu interrogatório judicial evidenciam a coautoria, ainda que tente se esquivar do delito. Ele admitiu que ouviu o barulho, bem como admitiu que viu o comparsa retornando com um objeto em mãos, situação que lhe evidenciava com clareza a prática do crime.

Noto, ainda, que Hamilton, quanto interrogado judicialmente, modificou sua versão. Isso porque na delegacia e afirmou que "[...] ele pediu para parar, quando ele desceu e adentrou numa loja enquanto o interrogando o aguardava. Ao que percebeu a loja estava aparentemente fechada, e viu Vander ingressar na loja. Ouviu um barulho semelhante a um "estouro". Viu alguém dizer "alguém estourou a porta". De repente

Vander voltou correndo, na posse de algo na mão e Vander solicitou que o levasse até o Bairro Vila Virgínia [...] (fls. 07).

Ora, nota-se que na fase policial Hamilton admitiu expressamente ter presenciado o arrombamento da porta, a entrada do comparsa no estabelecimento e, em seguida, ter dado fuga a ele.

A versão de Hamilton de que estava apenas trabalhando de motoaxista não convence. Um trabalhador de boa-fé não se prestaria a conduzir, assistir a um crime furto e dar fuga ao furtador desinteressadamente. As circunstâncias fáticas verificadas em questão mostram que havia sim um vínculo subjetivo entre os agentes: Hamilton foi o motorista que conduziu o comparsa até o local, posicionou-se estrategicamente perto do local do furto e na sequência deu fuga ao comparsa. Noutro passo, Vander encarregou-se de desembargar, arrombar a porta e subtrair os bens, fugindo na sequência da garupa da motocileta.

A divisão de tarefas, com importante atuação de cada furtador, mostra que o crime de fato foi praticado em coautoria.

A qualificadora do rompimento de obstáculo está devidamente demonstrada pelo laudo pericial de fls. 277/280, bem como pelas declarações da vítima e confissão do corréu Vander, o qual relatou que, para ingressar no interior do estabelecimento, foi necessário arrombar a porta de vidro.

Quanto à qualificadora do concurso de agentes, esta também se encontra devidamente demonstrada pelas declarações da vítima e testemunha e imagens das câmeras de segurança de fls. 308/327.

Reitero que pelas imagens de fls. 310/316, observa-se que a motocicleta conduzida por Hamilton ficou estacionada quase defronte à loja furtada, tendo ele acompanhado toda ação delitiva de perto, dando fuga ao comparsa após a prática do delito. Portanto, não há dúvidas quanto ao vínculo subjetivo entre eles, sendo que cada qual agiu na empreitada criminosa de forma determinante.

Anoto que o fato de Hamilton ter permanecido na moto enquanto Vander ingressou no estabelecimento da vítima não torna sua participação de menor importância.

Entendo que sequer é partícipe, senão autor concursivo. Isso porque o agente que conduz o comparsa até o local, aguarda do lado de fora dando cobertura e depois dá fuga, também é executor direto do delito. Ao assim agir, pratica materialmente a conduta de furto, sendo igualmente responsável àquele que desembarca e subtrai o bem.

Em casos tais, muito menos se poderá dizer que a conduta desse motorista seja de menor importância para o bom sucesso do delito.

Nesse sentido, a decisão do E. TJSP:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Recurso da Defesa - Preliminar de ausência de apreensão e perícia do objeto material - Inadmissibilidade - "A materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima - Igualmente para a configuração da causa de aumento utilização de arma de fogo, bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que esta não seja apreendida - Preliminar rejeitada. Mérito Absolvição por insuficiência probatória - Improcedência - Os depoimentos da vítima e testemunhas, são suficientes para a comprovação dos fatos descritos na denúncia - Participação de menor importância - Não cabimento - Réu que exerceu participação relevante na empreitada criminosa, já que, juntamente com seus comparsas, serviu de motorista para estes para o sucesso da empreitada criminosa - Afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo - Inviabilidade - Majorante comprovada pelo depoimento da vítima - Para o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, §, 2º, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova - Precedentes STF - Pretendida fixação de regime prisional mãos brando - Inviabilidade - A gravidade dos fatos justificam o regime inicial fechado - Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não se apresenta socialmente recomendável - Recurso defensivo improvido" (TJSP. Apelação Criminal nº 0015266-60.2017.8.26.0348. Relator: Sérgio

Ribas. Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 24/10/2019)

Reconheço, ainda, a causa de aumento de pena prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal.

Isso porque, é pacífico nos Tribunais Superiores a possibilidade da incidência da causa de aumento de pena do §1º no casos de furto qualificado, previstos no §4º do artigo 155.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CP. APLICABILIDADE. (HC 161.861, Rel. Min. Luis Roberto Barroso)

Habeas corpus. Penal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II). Condenação. Incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) nas formas qualificadas do crime de furto (CP, art. 155, § 4º). Admissibilidade. Inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ordem denegada. 1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador. 2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) -, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. 4. Ordem denegada." (HC 130.952, Rel. Min. Dias Toffoli). (grifei)

[...] VII - A alegação da impossibilidade de aplicação da causa de aumento de pena pelo repouso noturno, nos casos de furto qualificado, sequer ultrapassa o conhecimento, uma vez que este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "a causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminoso em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto." (HC 424.098/SC, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/2/2018). [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 429.695/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018) (grifei)

Além disso, em que pese ainda haver pessoas na rua, o furto ocorreu durante o repouso noturno (conforme denúncia, às 21h35), ou seja, quando as pessoas de um modo geral estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios porque anoiteceu.

É evidente que os acusados, por ser durante o repouso noturno, aproveitaram que o estabelecimento comercial "Ortopedia Jácomo" estava mais vulnerável à prática de delitos e, assim, em razão da menor vigilância, decidiram, juntos, praticar o furto.

Observo que há farta jurisprudência nesse sentido no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça de São Paulo:

PENAL. FURTO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO CASO DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATÉRIA DE DIREITO. SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. FURTO PRATICADO EM

ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. Segundo o entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, a majorante do período noturno pode incidir nas hipóteses de furto qualificado. 4. A majorante do §1º do art. 155 do Código Penal deve ser reconhecida mesmo nas hipóteses de furto praticado em estabelecimento comercial, tendo em vista a maior vulnerabilidade do patrimônio no período de repouso noturno. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1724452/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. OFENSA À CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. COMPATIBILIDADE ENTRE A FORMA QUALIFICADA DO CRIME DE FURTO E A CAUSA DE AUMENTO DO § 1º DO ART. 155, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] V - Em relação à causa de aumento do furto praticado durante o repouso noturno, a r. denúncia destacou a incidência da referida majorante, com a exposição de todos os fatos juridicamente relevantes e necessários à tipificação do delito. VI - Para a incidência da majorante prevista no art. 155, parágrafo 1º, do Código Penal, basta que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas, veículos e estabelecimento comercial. Assim, considerando que houve a correlação entre os fatos atribuídos ao acusado na denúncia e a fundamentação levada a efeito pelo magistrado, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento de pena capitulada no parágrafo 1º, do art. 155, do Código Penal. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 429.695/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018) (grifei)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal incide na hipótese de furto praticado em estabelecimento comercial no período do repouso noturno, em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminoso em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração. Precedentes. 2. Recurso especial provido. (REsp 1193074/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 15/03/2013) (grifei)

APELAÇÃO - Furto simples majorado pelo repouso noturno (artigo 155, § 1º, do Código Penal) - Sentença condenatória - Apelação defensiva requerendo a absolvição do réu, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância. Alternativamente, pugna pelo afastamento da majorante relativa ao repouso noturno, sob o argumento de que o delito não ocorreu em residência habitada - Descabimento - Absolvição - Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - [...] A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando - Furto que, ademais, foi praticado durante a madrugada e em frente à residência da vítima, enquanto esta lá repousava - Ausência de insurgência contra o regime fixado pela primeira instância para cumprimento da pena corporal - Sentença condenatória mantida - RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0016169-66.2017.8.26.0196; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro: 02/04/2019) (grifei)

FURTO - materialidade - auto de exibição e prova oral que comprovam a subtração de

uma mochila pertencente ao estabelecimento comercial. FURTO - autoria - versões dos réus que restaram contraditórias, carecendo de credibilidade - afastamento - versão de vítima confirmando o furto praticado por dois indivíduos - testemunha presencial confirmando a detenção dos réus em poder da res furtiva - depoimento policial coerente com o restante dos fatos apresentados - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade. [...] REPOUSO NOTURNO - estabelecimento que não estava em horário de funcionamento - delito ocorrido durante a madrugada. [...] (TJSP; Apelação Criminal 0000436-82.2018.8.26.0533; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Bárbara D'Oeste - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/03/2019; Data de Registro: 26/03/2019) (grifei)

Por fim, coleciono decisão do TJDF:

Para configurar-se a causa de aumento de pena prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal, basta que o furto tenha ocorrido durante o período noturno, sendo irrelevante se a vítima estava ou não em repouso. Da mesma forma, irrelevante é o local onde ocorreu o furto, pois o tipo penal tutela o patrimônio que durante a noite, torna-se mais vulnerável dada a carência de vigilância (TJDF, Apelação Criminal 2007031002152-5-DF, 1ª T.C., rel. João Egmont, 22/07/2010, v.u.)

Passo, então, à dosimetria das penas.

VANDER CRISTIANO RIBEIRO

Na primeira fase, quanto às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, além da reincidência que será tida na segunda fase, verifico que o réu possui várias processos criminais (fls. 151/158), a indicar personalidade voltada a prática de delitos patrimoniais. Além disso, são duas as qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), sendo de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal: ("As circunstâncias de um furto praticado sob a égide de duas qualificadoras são mais graves que as cometidas sob o manto de uma única, de modo que um furto bi-qualificado não poder receber o mesmo tratamento, no que diz respeito à fixação da pena-base, do que o autor de um furto unqualificado" - RJDTCRIM 24/225 - e "Censurável é a prática de aplicar-se única e mesma reprimenda, quer se trate de uma ou mais qualificadoras. Evidencia maior periculosidade a pluralidade de qualificadoras, reclamando por via de consequência, apenação mais severa que a correspondente a uma só" - RJDTCRIM 10/115). Por esses motivos, fixo a pena-base em 1/3 acima de seu mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (Certidão de Distribuição Criminal de fls. 154 - Processo 0067273-79.2013.8.26.0506), portanto, presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, "d", do CP. Tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, compenso-as. Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena do §1º, razão pela qual aumento a pena em 1/3 fixando-a em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pena que torno definitiva, pois não há outras causas de aumento ou diminuição da pena. Tendo em vista a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial para cumprimento será o semiaberto. Pelas mesmas razões, incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena (artigos 44, I e II, e 77, "caput" e inciso I, ambos do CP).

HAMILTON DE OLIVEIRA ROMERO

Na primeira fase da dosimetria da pena, além da reincidência que será tida na segunda fase, verifico que o réu possui várias processos criminais (fls. 146/150), a indicar personalidade voltada a prática de delitos patrimoniais. Além disso, são duas as qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), sendo de

rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal: ("As circunstâncias de um furto praticado sob a égide de duas qualificadoras são mais graves que as cometidas sob o manto de uma única, de modo que um furto bi-qualificado não poder receber o mesmo tratamento, no que diz respeito à fixação da pena-base, do que o autor de um furto unqualificado" - RJDTACRIM 24/225 - e "Censurável é a prática de aplicar-se única e mesma reprimenda, quer se trate de uma ou mais qualificadoras. Evidencia maior periculosidade a pluralidade de qualificadoras, reclamando por via de consequência, apenação mais severa que a correspondente a uma só" - RJDTACRIM 10/115). Por esses motivos, fixo a pena-base em 1/3 acima de seu mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (Certidão de Distribuição Criminal de fls. 146/147 - Processo 0000170-46.2014.8.26.0530), portanto, presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP, razão pela qual agravo a pena em 1/6 para fixa-la em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena do §1º, razão pela qual aumento a pena em 1/3 fixando-a em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pena que torno definitiva, pois não há outras causas de aumento ou diminuição da pena.

Tendo em vista a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial para cumprimento será o fechado.

Pelas mesmas razões, incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena (artigos 44, I e II, e 77, "caput" e inciso I, ambos do CP).

Dispositivo.

Posto isto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR VANDER CRISTIANO RIBEIRO à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e HAMILTON DE OLIVEIRA ROMERO à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, ambos como incursos no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Mantenho os acusados presos, por considerar o risco concreto de reiteração delitativa, em detrimento da ordem pública (artigo 312 do CPP), o que se evidencia pelo modo de agir e antecedentes em crimes patrimoniais semelhantes, provado o perigo que sua liberdade causa à sociedade, além dos outros fundamentos expressos na decisão acerca da custódia preventiva que ainda se encontram presentes.

Expeçam-se mandados de recomendação em desfavor dos réus na prisão em que se encontram, bem como guias de execução provisória, nos termos da Resolução n. 113 do Conselho Nacional de Justiça, procedendo-se, imediatamente, ao cálculo de pena.

Observe-se o regime inicial.

Transitada em julgado, tome a Serventia as seguintes providências: 1) Proceda-se ao cômputo da presente decisão em dados estatísticos, ex vi do Art. 809 do Código de Processo Penal; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do Art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 3) Lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo; 4) Extraiam-se as guias de execução definitiva conforme Art. 105 da Lei de Execução Penal, observando-se o regime inicial fixado na condenação. Expeçam-se as comunicações necessárias.

Deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos prevista no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, pois não há pedido nesse sentido.

Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao corréu Hamilton.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, observando que ambos são beneficiários da gratuidade.

P. I. C.

Ribeirão Preto, 14 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA